

1501017-14.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas."

(TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a):

Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA.

DESCCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501017-14.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2174055/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9, 134/2001 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO SILVA ARAUJO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 01 dias do mês de novembro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora Pública, Dra. Daniela Batalha Trettel. Apresentados o acusado CARLOS ALBERTO SILVA ARAUJO e a testemunha arrolada pela defesa Fabio Luis Gonçalves Hilsdorf.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi colhido o depoimento da testemunha comum (Fabio) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às

partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, CARLOS ALBERTO SILVA ARAÚJO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de julho de 2021, por volta de 10h30min, na Rua Elpídio Teixeira da Silva, n.º 290, Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, CARLOS ALBERTO SILVA ARAÚJO, qualificado e indiciado às fls. 04 e 11/21, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 06 (seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 1,5g (um grama e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o denunciado trazia consigo porções de cocaína para comercialização em via pública que reiteradamente são registradas ocorrências policiais e prisões em flagrantes relacionadas ao tráfico de drogas. Após atender o motorista de um veículo na rua e disfarçadamente manejar algo na calçada, movimentação típica de mercancia ilícita, CARLOS foi abordado por investigadores que realizavam atividades veladas no local. Nos bolsos de sua calça foram apreendidos 03 (três) eppendorfs de cocaína e R\$44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie. Na calçada onde foi visto escondendo ou retirando algo, foram encontrados outros 03 (três) idênticos eppendorfs com a mesma droga (foto fls. 09). Na delegacia, CARLOS ficou silente (fls. 04).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de apreensão fls. 07 e laudos periciais fls. 23/25 e 79/81). Diante das circunstâncias, em especial o local amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, a visualização de movimentação típica de mercancia, a apreensão de cocaína e dinheiro em espécie, é certo que o denunciado trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Rogério José da Silva, policial civil, narrou que transitava com a viatura descaracterizada pelo local dos fatos, ponto de tráfico, e viu uma pessoa em movimentação típica de tráfico. Essa pessoa fez contato com um motorista de um Renault CLIO/preto (placas não anotadas). Essa pessoa pegou algo no chão e guardou no bolso. Quando o abordou, encontrou três eppendorfs no bolso dele e R\$43,00. No chão, mais três eppendorfs. Eram pinos idênticos aos que foram encontrados em seu bolso. As pessoas que faziam contato com o réu não permaneciam no local, faziam contato e iam embora.

Fábio Luiz Hilsdorf – Policial Civil – narrou no mesmo sentido. Confirmou que viu o réu tinha entregado algo ao motorista de um veículo. Na sequência, viu que ele escondera alguma coisa na calçada, permanecendo no local, enquanto o veículo foi embora. Permaneceu observando e o viu novamente pegando algo na calçada e colocar no bolso. Abordou-o e encontrou três eppendorfs com cocaína e dinheiro. Na calçada, encontrou mais três pinos com cocaína. Conduziu o réu até a Delegacia de Polícia e o flagrante foi flagrado. A observação à conduta do réu durou de dez a quinze minutos. Não conhecia o réu. O local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu também recebeu algo em troca do motorista do veículo, mas não foi possível ver o que recebeu e o que entregou. O réu nada falou sobre a droga. Interrogado, o réu disse que foi ao local com a namorada para comprar entorpecentes. Que comprou três eppendorfs de cocaína de um traficante que estava lá por trinta reais. Foi abordado na sequência. Disse ao policial que tinha comprado a droga para uso próprio.

Narrativa vazia, desconectada das provas dos autos. Os policiais nada falaram sobre eventual namorada do réu. Nada falaram sobre pessoa que pudesse estar ali traficando, além do réu, e não é crível que o traficante deixasse o local abandonando as drogas antes da chegada dos policiais. Aliás, estes ficaram por dez minutos no local e o réu esteve o tempo todo ali, posicionado para o tráfico,

mexendo onde estavam as porções, na calçada. Ademais, sequer trouxe a namorada para depor a seu favor.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (TJ/SP, Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Importante considerar que após ganhar liberdade provisória nos presentes autos em 29.06.2021 (alvará fls. 62/63), em 12.08.2021 novamente foi preso em flagrante por tráfico de drogas (vide autos n.º 1501248-41.2021.8.26.0599- 1ª Vara Criminal de Piracicaba), circunstância que demonstra que o réu está envolvido com o tráfico e trazia as drogas para comércio e não consumo próprio.

DA PENA

O réu é primário.

Incide a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, reconheceu que o chamado "tráfico privilegiado de drogas" não tem natureza hedionda.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento da Corte Superior e cancelo a Súmula 512.

Com isso, entendo possível, no presente caso, acompanhando o posicionamento das Cortes Superiores, a fixação de regime aberto e a substituição por restritiva de direitos.

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

DO PEDIDO FINAL

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal, nos termos da inicial.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, CARLOS ALBERTO SILVA ARAÚJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 109 e 110), no dia 28 de julho de 2021, por volta de 10h30, na Rua Elpidio Teixeira da Silva, n.º 290, Vila Cristina, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, Carlos Alberto trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 06 (seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 1,5g (um grama e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, segundo a inicial, o denunciado trazia consigo porções de cocaína para comercialização em via pública que reiteradamente são registradas ocorrências policiais e prisões em flagrantes relacionadas ao tráfico de drogas. Após atender o motorista de um veículo na rua e disfarçadamente manejar algo na calçada, movimentação típica de mercancia ilícita, CARLOS foi abordado por investigadores que realizavam atividades veladas no local. Nos bolsos de sua calça foram apreendidos 03 (três) eppendorfs de cocaína e R\$44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie. Na calçada onde foi visto escondendo ou retirando algo, foram encontrados outros 03 (três) idênticos eppendorfs com a mesma droga.

O policial Fabio Luiz Hilsdorf, na delegacia (fls. 2), informou: "Que é Policial Civil atuando no GOE/DEINTER e, na data de hoje, tinha como outro componente de guarnição o Policial ROGERIO, enquanto transitavam com a viatura descaracterizada pelo bairro Vila Cristina/Monte Cristo, muito conhecido por possuir alta incidência de tráfico de entorpecentes. Ao perceber uma movimentação estranha de um indivíduo que, após entregar algo para um motorista de um Renault CLIO/preto escondia algo sob a calçada defronte à residência, situada à Rua Elpidio Teixeira da Silva, 290. Posteriormente, após a equipe em campana acompanhar a sua movimentação, retirou algo daquele mesmo local outro objeto, guardando-o em seguida em seu bolso. Nesta oportunidade, o agora indiciado CARLOS ALBERTO SILVA ARAUJO, foi abordado e encontrado em seu poder 3 pinos de substância esbranquiçada, aparentando ser entorpecente cocaína, além da quantia de R\$ 44,00 nos bolsos de sua calça. No local onde utilizava para homiziar, foram encontrados mais três (3) pinos idênticos aos que foram encontrados em seu bolso, foi dado voz de prisão e ratificada pela Autoridade Policial, sendo submetido ao exame de corpo de delito e encaminhado à Cadeia Competente.

O policial Rogério José da Silva, na delegacia (fls. 3), informou o mesmo que seu companheiro de farda.

Na delegacia, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer silente. Juntadas certidão de objeto e pé (fls. 27 e 28), que comprova que o acusado é primário e de bons antecedentes.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo laudo de fls. 23 à 25.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente ouvido o Policial Fabio Luiz Hilsdorf. Estava fazendo rondas no local com viatura descaracterizada por se tratar de região conhecida como ponto de venda de entorpecentes. Avistaram Carlos se aproximar de um carro, entregar algo e receber algo em troca, e ir até um buraco na calçada. Momentos depois, ele tornou a mexer nesse buraco na calçada e colocou algo em seu bolso. Decidiram pela abordagem. Em revista pessoal, no bolso de Carlos, localizaram 3 pinos de cocaína e 44 reais. No local em que ele mexia, localizaram outras 3 porções de cocaína iguais às que estavam com o réu. No momento da abordagem, o acusado nada disse ao depoente - que foi o responsável pela sua revista. No momento em que foi fazer a busca na calçada, o réu ficou sob o cuidado do policial Rogerio e não sabe se ele disse algo. Ficaram em campana de 10 a 15 minutos. Não conhecia o réu.

b) Por fim, interrogado o acusado Carlos Alberto Silva Araujo. Estava no local, pegou drogas, estava em companhia da namorada. A viatura virou a esquina e lhe

abordou. Acharam 3 tubinhos de cocaína com ele. Foi ao local, em companhia da sua namorada, para comprar os entorpecentes. Comprou 3 porções de cocaína e pagou 30 reais. Comprou do traficante que estava no local. Conhece a pessoa de vista, é um homem, mas não sabe dizer o nome. Ao chegarem no ponto de tráfico, pediram a droga, o traficante foi a um local, pegou os entorpecentes e lhe entregou. Isso demorou aproximadamente 5 minutos. Nisso, foi para um lado e o traficante foi para outro. Tinha consigo 3 porções de cocaína. O resto da droga, os policiais disseram que acharam, mas não sabe onde exatamente, pois já estava detido na viatura. A namorada foi liberada. Falou para o policial que tinha acabado de comprar a droga e apontou quem era o traficante e onde ele estava. O traficante fugiu, mas ele indicou o local em que estava. A viatura não era descaracterizada, estava escrito GOE. No momento, não está mais usando drogas. Na época, estava usando cocaína e era difícil ficar sem. Tinha 77 reais. Quando foi abordado, tinha 44 reais em dinheiro e 3 reais em moedas. O dinheiro era do seu serviço. Não conhece os policiais. Havia mais pessoas no ponto de tráfico. Quando a viatura veio, as pessoas dispersaram. Acha que foi abordado porque atravessou a rua quando viu a viatura.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória.

Eventual sentença de condenação estaria embasada nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal da acusada. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, ainda que se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminent Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho,

SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista da Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a

Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida do acusado não é excessiva, corroborando as declarações do acusado no sentido de que é usuário.

Isso posto, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não tendo sido demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências.

a) Absolução por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição, tendo em vista a inconstitucionalidade do referido tipo. Com efeito, o art. 28 da Lei de Drogas é inconstitucional por ferir o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização

da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344). Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, fixada tal premissa, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas. Isso posto, diante da alegação ora invocada, de rigor que seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, afastando-se a imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas, o que torna imperiosa a sua absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Porém, rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Na remota hipótese de condenação pela prática de tráfico de drogas, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior. Da mesma forma, o réu é primário e a quantidade de drogas não é exacerbada. Tais circunstâncias, portanto, recomendam a pena-base no patamar mínimo.

Aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo, sendo certo que, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

Ainda, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o afastamento do privilégio com base apenas na quantidade ou na qualidade

da droga apreendida:

Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. (STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022. Informativo 731)

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, reconhecido o privilégio, de rigor a fixação do regime inicial aberto.

Ainda que não aplicado o redutor do art. 33, §4º, da LD, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou,

se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). O denunciado está respondendo ao processo em liberdade, compareceu aos atos processuais e não indica que se furtará ao processo.

Em seguida pela MM.Juiza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

CARLOS ALBERTO SILVA ARAÚJO qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de julho de 2021, por volta de 10h30, na Rua Elpidio Teixeira da Silva, nº 290, Vila Cristina, nesta

cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 06 (seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 1,5g (um grama e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu trazia consigo porções de cocaína para comercialização em via pública que reiteradamente são registradas ocorrências policiais e prisões em flagrantes relacionadas ao tráfico de drogas.

Nos bolsos de sua calça foram apreendidos 03 (três) eppendorfs de cocaína e R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie. Na calçada onde foi visto escondendo ou retirando algo, foram encontrados outros 03 (três) idênticos eppendorfs com a mesma droga (foto fls. 09).

Na Delegacia, Carlos ficou silente (fls. 04).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de apreensão fls. 07 e laudos periciais fls. 23/25 e 79/81).

Diante das circunstâncias, em especial o local amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, a visualização de movimentação típica de mercancia, a apreensão de cocaína e dinheiro em espécie, é certo que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls.100/108), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 112/113).

O réu foi notificado (fls. 118) e apresentou defesa prévia, na qual requereu o envio dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que se manifeste acerca da oferta de acordo de não persecução penal e alegou inocência (fls. 122/124).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 130/132). O réu foi citado (fls. 157).

O Procurador-Geral de Justiça insistiu na recusa de oferta do acordo de não persecução penal (fls. 141/150).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns (fls. 177/179), sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 07, na fotografia de fls. 09, no laudo de constatação preliminar de fls. 23/25 e no exame químico-toxicológico de fls. 79/81, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase policial, o réu permaneceu calado (fls. 04).

Em Juízo, o réu afirmou que estava no local pegou a droga no local. Estava com a namorada, assim que estavam saindo do local, a viatura virou a esquina e foi abordado. Os policiais encontraram consigo 03 pinos de cocaína. Foi ao local, com a namorada, comprar entorpecente. Adquiriu 03 envelopes de cocaína, por R\$ 30,00. Um rapaz que estava lá lhe vendeu a droga, mas não sabe seu nome, embora o conheça de vista. pediram a droga, ficaram parados, o rapaz foi buscar a droga e lhes entregou. Viraram as costas e passaram a descer. O traficante foi indo para o outro lado. Quando estavam indo embora, a viatura apareceu e foram abordados. O resto da droga, os policiais disseram que encontraram, mas não viu, porque estava dentro da viatura. Sua namorada foi liberada ali mesmo. Perguntaram se ela tinha algo no bolso e o que tinha na mão, mas como não era nada de ilícito, ela foi liberada. Falou aos policiais que tinha acabado de comprar a droga. Quando foi abordado, não viu mais o traficante, que fugiu. A viatura estava escrito Goe, não era descaracterizada. Não sabe o modelo do carro. Na época, fazia uso de cocaína e era difícil ficar sem consumi-la. Tinha R\$ 77,00 consigo, comprou R\$ 30,00 de drogas e sobrou R\$ 47,00. O dinheiro era do seu serviço. Havia outras pessoas no ponto de drogas, mas quando chegou a Polícia o pessoal saiu cada um para um lado. Quando avistou a viatura, tentou sair de um lado para o outro da calçada e acha que foi

isso que o fez ser abordado.

A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial civil Fábio Luiz Hilsdorf contou que no dia dos fatos, estava com Rogério, numa viatura descaracterizada, dando voltas pelo local, já conhecido por tráfico de drogas. Observaram o Renault Clio parou, o réu entregando algo para o motorista, que deixou o local e o réu colocou alguma coisa na calçada, permanecendo no mesmo local. Viram o réu entregando algo para o motorista, porque passavam ao lado. Estranharam e ficaram campanando o réu. Notaram que o réu mexeu no buraco na calçada e colocou algo no bolso. Resolveram abordá-lo. Foi feita revista pessoal e, no bolso, havia 03 pinos de cocaína e R\$ 44,00. No buraco na calçada, encontraram mais 03 pinos com cocaína. Diante das evidências, deram voz de prisão ao réu. Na abordagem, o réu nada disse. Se ele falou algo depois, como o réu ficou com Rogério, enquanto foi verificar o buraco, não sabe. O réu anda falou sobre a droga. Ficaram de 10 a 15 minutos no local, observando, porque o local é complicado. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o também policial civil Rogério Jose da Silva informou que saíram com viatura descaracterizada e foram ao local, para fazer campana, porque o local já era conhecido por tráfico de drogas. No local, avistaram apenas uma pessoa. Não conhecia o réu. Avistaram o réu fazendo contato com outras pessoas, entregando algo e recebendo dinheiro. Ele fez contato com um Renault preto e, identificado como o suposto vendedor, abordaram o réu. Viram que o réu retirava algo do chão e guardava no seu bolso. Na abordagem, encontraram com o réu, 03 microtubos de cocaína e R\$ 44,00. No chão, onde o réu mexia, encontraram mais 03 microtubos. Não se recordou o que o réu falou sobre a droga e o dinheiro. Toda a droga estava embalada da mesma forma. O dinheiro era trocado. As pessoas que fizeram contato com o réu, depois do contato, foram embora (fls. 177/179).

A primeira questão a ser analisada é sobre a posse da droga.

O réu, na fase policial, ficou silente. Judicialmente, o réu alegou que tinha ido adquirir drogas, comprou 03 porções de cocaína e, quando deixava o local, foi abordado. Aduziu que estava acompanhado da namorada, que foi liberada no local. Os investigadores de polícia narraram que foram ao local, com viatura descaracterizada, porque tinham conhecimento da prática de tráfico de drogas no local. Ao passarem pelo réu, viram que ele entregou alguma coisa a um motorista de um Renault Clio. Mesmo depois desse contato, o réu continuava no local. Também presenciaram o réu escondendo algo sob a calçada. Um tempo após, visualizaram o réu indo até o determinado local e pegando algo do chão e colocando na cintura. O réu foi abordado e encontraram em seu poder 03 microtubos de cocaína e R\$ 44,00, no bolso da calça. No local onde viram o réu mexendo, um buraco na calçada, foram localizados mais 03 microtubos de cocaína, idênticos àqueles encontrados no seu bolso.

Com efeito, temos duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, que confirma que apenas 03 porções de cocaína estivessem em seu poder e guarda, e a dos policiais, segundo os quais o réu foi abordado com parte da droga no bolso e o restante foi encontrado onde o réu mexendo.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

O depoimento dos policiais encontra amparo no fato de que parte das drogas foram encontradas exatamente no local onde viram o réu mexer, ou seja, se não tivesse presenciado a retirada da droga do local, não haveria o flagrante.

Ressalto que o depoimento dos policiais foi seguro e coeso.

Ademais, ao contrário da narrativa do réu, ele foi observado de forma velada por 10 ou 15 minutos, de forma que não estava ali apenas para adquirir drogas e, depois, estava indo embora, como quis fazer crer.

Por fim, a suposta namorada, somente referida pelo réu, não foi por ele arrolada. Assim, entendo que a palavra dos policiais se sobrepõe à negativa do réu.

Por fim, como já vem decidindo a jurisprudência, a palavra de policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, se corroborado por outros meios de prova, como no caso concreto, com a localização da droga no local onde o réu foi visto mexendo.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destarte, não havendo nenhuma prova de que os policiais civis tivessem interesse em prejudicar o réu, até porque nem o conheciam, deve-se dar crédito ao depoimento seguro e firme das testemunhas.

Comprovado o envolvimento do réu com a droga, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS – Ver. 695102699 – Rel. José Eugênio Tedesco – RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS – Ver. – Rel. Rubens Rebelo Magalhães – RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu aduziu que o entorpecente que trazia consigo era para seu próprio consumo. A prova dos autos, contudo, confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, o réu estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e ali permaneceu, mesmo depois de ter contato com o motorista do veículo Clio.

Os policiais civis visualizaram cenas características de tráfico de drogas, com o réu fazendo contato breve com motorista, para quem entregou alguma coisa, escondendo algo na calçada, depois. Esse fato levou os policiais a fazerem monitoramento velado rápido, no qual viram que o réu continuou no mesmo local e ainda mexeu na calçada.

É típica a conduta dos traficantes que ficam com pouca droga em seu poder e escondem o restante nas proximidades, onde possam acessar com facilidade e também possam ter a visão, para poderem cuidar da mercadoria escondida.

A droga tinha pouca quantidade (06 microtubos), mas a situação presenciada traz a certeza de que o entorpecente tinha como destinação o comércio ilícito, já que usuários não deixam seu entorpecente escondido na calçada.

Ainda, com o réu havia R\$ 44,00, cuja origem lícita não foi comprovada, embora tivesse mencionado que era do seu trabalho.

Assim, a visualização de movimentação típica de mercancia, a apreensão da cocaína e

de dinheiro em espécie; tudo revela que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu não possui antecedente criminal de forma que a sua pena-base deve ser no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicado ao caso concreto. Embora o réu seja primário e a quantidade de entorpecente apreendido não era considerável, ele ganhou a liberdade nestes autos em 29/06/2021 (fls. 75/76), mas foi novamente preso, pela prática do mesmo delito, em 12/08/2021 (processo nº 1501248-41.2021.8.26.0599, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal local, no qual foi condenado definitivamente por tráfico de drogas privilegiado, com sentença transitada em julgado em 08/11/2021), de forma que fica claro que se dedica a atividades criminosas. Ressalvo que não se está diante da aplicação do Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que, no caso em comento, embora o trânsito em julgado do feito nº 1501248-41.2021.8.26.0599 tenha se dado após a prática deste crime, não podendo ser reconhecido como Maus antecedentes ou reincidência, serve para demonstrar a reiteração da conduta. Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, na medida em que o delito continua a ser equiparado aos hediondos e fomenta a prática de outros

delitos, em especial contra o patrimônio. Além disso, mesmo em liberdade provisória, o réu retornou à prática delitiva, o que permite a certeza de que outro regime não seria suficiente para mantê-lo longe da delinquência.
Pena final: reclusão de 05 anos, regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR CARLOS ALBERTO SILVA ARAÚJO, qualificadas nos autos, nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos, regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima.

O montante de pena aplicada impede a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O réu encontra-se em liberdade e assim continuará caso deseje recorrer desta sentença.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendidos na posse do réu (comprovante de depósito a fls. 78) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o réu manifestou desejo de recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito: "recebo o recurso interposto pelo réu, devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria